

1501479-55.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - e-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501479-55.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE e RONALDO BATISTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, subtraíram, em proveito da dupla e em concurso de pessoas, mediante rompimento de obstáculo (i) 42 metros de cabo PP 4x10, avaliados em R\$2.167,00 e (ii) 14 metros de cabo PP 4x4, avaliados em R\$291,00, pertencente à SABESP.

É da denúncia que, na data dos fatos, os denunciados, em unidade de desígnios, danificaram as estruturas da estação de tratamento de esgoto da SABESP. Apurou-se que, no local, lograram subtrair os objetos supracitados.

Ocorre que Policiais Militares receberam, via COPOM, a informação sobre o furto, e se depararam com os denunciados, que apresentavam as características passadas empurrando um carrinho de reciclagem com diversos objetos, entre os quais estavam a res furtiva. Durante a abordagem, houve êxito na apreensão dos bens subtraídos.

Recebida a denúncia (fls. 130/131), os réus foram citados (fls. 160 e 162) e ofertaram respostas à acusação (fls. 170/174). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu Ronaldo interrogado. E, decretada a

revelia do réu Rafael diante de sua ausência injustificada.

Encerrada a instrução criminal, por meio de memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório. Alternativamente, requereu o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação do regime aberto. É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, o caso verte uma situação de emendatio libelli, consoante tipificação atribuída não correspondente aos fatos narrados, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual reproduzo abaixo:

Art. 383 - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

De início, verifico que é necessário ser feita uma alteração na capitulação do delito pelo qual os réus foram denunciados, tal alteração pode ser feita de ofício e independente de aditamento da denúncia ou manifestação da defesa, ademais, tratando-se de emendatio libelli, é tão somente um re-enquadramento jurídico, não alterando os fatos descritos na denúncia, não configurando nenhum tipo de prejuízo aos réus, já que eles se defendem dos fatos descritos e não da capitulação.

Na capitulação da denúncia constou, artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo. Trata-se de um erro material, na qual deverá ser considerado o inciso I, que se refere ao rompimento de obstáculo narrado na denúncia, em vez do II.

Considerando que a tese defensiva se baseou nos fatos narrados na denúncia, sendo que estes não estão sendo alterados, mas sim apenas à capitulação do delito.

Necessário atentar-se, ainda, que é ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados, independentemente da tipificação atribuída.

A materialidade está confirmada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/12), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 17), pelo auto de avaliação (fl. 18), pelos anexos fotográficos de fls. 53/66, pelo laudo pericial (fls. 211/219) e pela prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

O representante da vítima Elizeu Vagner Vieira, disse que no período, ocorreram dez ou onze casos de furto. Em um deles, localizaram duas pessoas entrando na estação de tratamento. A Polícia foi acionada e conseguiram prender os invasores. Disse que, neste caso, houve a recuperação dos cabos subtraídos, que foram avaliados em aproximadamente três mil reais. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que estava no local na data do fato. Disse que, no dia, houve o corte do arame farpado, que compõe a cerca, assim como poste de alvenaria. Os denunciados romperam a cerca para entrar no local. Às perguntas da Defesa, disse que os réus desceram sentido cidade/bairro, passaram por um acesso pelo matagal e sumiram na estação de tratamento. Afirmou que tem filmagem, mas não sabe se foi apresentada a Autoridade Policial. Indagado, disse que viu três pessoas, mas depois foram presas duas pessoas, que foram reconhecidas pelo depoente.

A testemunha policial militar Zaqueu de Carvalho, disse que foram acionados, via COPOM, para averiguar quatro indivíduos, que estavam próximo a entrada da cidade, que é um local próximo a SABESP. Durante o deslocamento, viram dois indivíduos com as mesmas características recebidas. Um deles, Ronaldo, estava empurrando um carrinho. Diante disso, fizeram a abordagem. Na busca pessoal, não houve apreensão de algo ilícito. Porém, no carrinho, foram encontrados sacos de cimentos vazios contendo rolos de fio. Os acusados não indicaram a procedência dos objetos. Constataram que era produto de ilícito e deram voz de prisão. Prosseguiram as diligências, mas não encontraram os outros dois suspeitos. Relatou que viram

painéis depredados, por vandalismo e vários fios cortados com a mesma bitola que Ronaldo estava levando. Após, todos foram encaminhados ao plantão, ratificando-se o flagrante. Às perguntas da Defesa, disse que os fios eram grossos e que não foram apreendidas ferramentas de corte. Ao fim, ratificou que os acusados não deram versão sobre o objeto.

Em seu interrogatório o réu Ronaldo Batista, disse que a acusação é falsa. Afirmou que é catador de reciclagem e, na beirada da pista, encontrou os fios. Alegou que não cortou os fios. Disse que os policiais verificariam o local onde encontrou os cabos, mas não houve essa diligência. Afirmou que Rafael também cata reciclagem. Disse que os cabos seriam levados para reciclagem. Alegou que nem imaginava que os bens pertenciam à SABESP, pois estavam ao lado da pista. Disse que não sabe o valor dos cabos subtraídos.

O réu RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE, deixou de comparecer à audiência, momento em que poderia esclarecer os fatos a seu favor.

Porém, referida versão apresentada por Ronaldo não é digna de credibilidade, vez que isolada e desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade. Ademais, não é crível que catadores de reciclagem deixem o centro urbano para vasculhar beira de rodovia em busca de reciclagem. E, ao contrário, a prova colhida em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia. Por sua vez, o representante da vítima reconheceu o material apreendido como sendo o furtado da estação, assim como os dois réus presos, na qual visualizou os acusados entrarem no local em atitude suspeita.

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

E em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz). "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório" (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

As qualificadoras referentes ao concurso de duas ou mais pessoas, e com rompimento de obstáculos à subtração da coisa ficam reconhecidas.

Ficou comprovado através do depoimento do representante da vítima, assim como o laudo pericial de fls. 211/214, que os agentes ingressaram no local do furto valendo-se de rompimento de obstáculos. No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida bem demonstra que os acusados praticaram o furto mediante concurso de duas ou mais pessoas, numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas. Lado outro, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Com efeito, se não houver o deslocamento, a outra qualificadora será simplesmente desconsiderada e contribuindo para a maior reprovação da conduta. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora.

Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (abaixo) utilizo uma das circunstâncias para fins de incidência da qualificadora e a outra para o como exasperação na primeira fase de dosimetria.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.

REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME). PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravamento regimental não provido.

(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da ação penal é a medida que se impõe.

Nos termos dos arts. 68 e 59 do CP, passo à dosimetria individual da(s) pena(s).

RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE

Na primeira fase, verifico que acusado não possui maus antecedentes (fls. 70), contudo, nos termos da Súmula 443, utilizo o rompimento de obstáculo como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar. Mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "c", e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto.

Nos termos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade, consistentes em prestação de serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada. E, prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo nacional vigente.

O descumprimento injustificado da restrição imposta resultará na conversão da pena restritiva de direitos pela reclusão, anteriormente, fixada (art. 44, § 4º, CP).

RONALDO BATISTA

Na primeira fase, verifico que o acusado possui maus antecedentes (fls. 71/78), tratando-se, inclusive, de reincidente específico. Além disso, nos termos da Súmula 443, utilizo o rompimento de obstáculo como exasperação na primeira fase de dosimetria, de forma que fixo a pena-base acima do mínimo legal de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e reconheço as agravantes da reincidência específica, conforme processos nº 0001727-85.2020.8.26.0521 e 1500052-

91.2019.8.26.0571 (fls. 79/83), de forma que agravo a pena intermediária em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Torna definitiva a pena em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado, uma vez, que o réu ostenta duas reincidências específicas, a evidenciar que qualquer outro regime, não se mostrará suficiente para a prevenção de novos delitos.

Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da pena imposta e da reincidência específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para:

- CONDENAR RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE, qualificados nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, em regime aberto, pelo artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, substituída nos termos acima.

- CONDENAR RONALDO BATISTA, qualificados nos autos, ao cumprimento de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, em regime fechado, por infração no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

RAFAEL THEODORO DELLEVEDOVE, poderá recorrer em liberdade.

RONALDO BATISTA, não poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante a instrução penal, se solto poderá voltar a delinquir ou se evadir. De fato, não se mostra razoável dar ao réu que respondeu o processo preso o direito de recorrer em liberdade se lhe foi impingida pena privativa de liberdade. Permanecem hígidos os motivos que ensejaram a segregação cautelar, exceto no que tange à garantia da instrução criminal que já se encerrou.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao procurador nomeado as (fls. 164).

Defiro justiça gratuita aos réus.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução oportunamente.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 22 de agosto de 2022.

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA